

# 第35問

A会社の技術職員甲は、同社が多額の費用を投じて研究開発した新技術に関する機密資料を保管し、時折は研究のため自宅に持ち帰っていた。B会社の社員乙は、A会社の機密を不正に獲得することを企て、甲に対し、その保管する当該資料のコピーの交付を依頼し、礼金の半額100万円を支払い、残りの100万円はコピーと引き替えに支払うことを約束した。甲は、コピーを作成する目的で当該資料を一旦社外に持ち出し、近くのコピーサービスでコピーを一部作成し、30分後に当該資料を会社の保管場所に返却した。その後甲は、発覚をおそれてそのコピーを渡さずにいたが、乙に督促されたため、個人的に所有する別の資料のコピーをA会社の機密資料のコピーであると偽って乙に渡し、残金の100万円を受け取った。

甲及び乙の罪責を論ぜよ。

(旧司法試験 平成元年度 第2問)

## 第1 甲の罪責

### 1 甲がコピー作成目的で資料を社外に持ち出した行為

- (1) 窃盗罪(235)の成否を検討すべきであるが、何をもって「財物」とであるとするのが問題となる(【論点】財物の意義～情報 司R1,旧H1-2,H13-2)。

情報自体には財物性が認められないし、財産的価値が低い媒体そのものを財物とみることも困難なので、情報が記載された媒体をもって、「財物」に当たると解することになる。

- (2) 次に問題となるのが、コピー作成目的での30分という短時間の社外持ち出しについて、不法領得の意思が認められるかどうかである(【論点】不法領得の意思 司H27,H29,旧H1-2,H19-2)。具体的には権利者排除意思の有無が問題となる。この点については、価値の消耗を伴うような利用態様であれば、短時間であっても、権利者排除意思が認められるとするのが一般的である。同様の事案で、裁判例でも可罰的だと解するものがある(東京地判昭55.2.14、東京地判昭59.6.15)。

また、資料そのものから経済的効用を得ているわけではなく、そこに記載されている情報から経済的効用を得ているから、利用処分意思が認められるかどうか問題となる。

- (3) なお、技術職員甲に機密資料の占有が帰属していれば、業務上横領罪(253)の成否が問題となるが、甲は管理権限ある者ではないと思われるから、問題すべき構成要件は窃盗罪でよいだろう(【論点】上下主従間の占有(占有の帰属) 司H21,R3,旧H1-2)。

### 2 甲が、別の資料のコピーを機密資料のコピーと偽って乙に渡し、残金の100万円を受け取った行為

- (1) 詐欺罪(246 I)の成否を検討する。構成要件を満たすことは明らかであるが、不法原因給付物であることとの関係が問題となる。

この点については、不法原因給付であることは詐欺罪成立の障害とならないと解する立場が一般的である。判例も肯定説を採る(最判昭25.7.4【百選Ⅱ46】)。

- (2) なお、当初受け取った100万円の返還を免れたとして、2項詐欺罪の成否を(も)検討することも考えられるが、問題文の事情から明らかではないから、省略することもできるだろう。

## 第2 乙の罪責

窃盗罪の教唆犯が成立する(61 I)。なお、甲に業務上横領罪を成立させている場合には、業務上横領罪の共犯の成否が問題となる(【論点】業務上横領と共犯 司H21,H24,予H27,旧H1-2)。

なお、共謀共同正犯と認定する場合には、意思連絡の有無を丁寧に検討する必要がある(意思連絡不要説に立つ場合には別論)。

有力な学説は、意思連絡が認められる場合を、

①実行行為の実質的な分担がある場合

②犯行準備の段階で互いに相談しあい、双方向的な影響を及ぼしあった上で、その中の一部の者によって犯罪が実行された場合

③背後者が実行担当者に指示命令をする場合

→この場合には、背後者に実行担当者との一体性を認めるに足りる関

総合 192 頁 論証 80 頁

総合 198 頁 論証 85 頁

総合 197 頁 論証 83 頁

総合 246 頁 論証 119 頁

与が認められるか（実行担当者に任せっぱなしにしているのではなく、その具体的な犯行内容などについて背後者が立ち入った関与をしているか）が重要となる

- ④実行担当者が背後者に心理的に拘束されるような関係があり、実行担当者が犯行計画を立案するに際しても、事実上、背後者の意を汲む必要があり、自身の自由な判断が制約されている場合

の4つに分類しているところ、本問は、①及び④に当たらないことは明らかであるから、②又は③のいずれかに当たる必要がある。具体的事案が明らかではないが、「企て」「依頼し」という乙の関与形態から、②又は③に当たると認定するのは、かなり困難ではないと思われる。

### 第1 甲の罪責

- 1 甲がコピー作成目的でA会社の機密資料を社外に持ち出した行為につき、窃盗罪（235）又は業務上横領罪（253）が成立し得る

↓

占有の帰属

↓

A社に帰属する

↓

- 2 窃盗罪の成立要件の検討

↓

「財物」性

↓

情報が化体されていることで「財物」足りうる

↓

「他人の」「窃取」

↓

故意（38 I）

↓

不法領得の意思

↓

①権利者排除意思、②利用処分意思

↓

あてはめ

↓

甲に窃盗罪が成立する

↓

- 3 別の資料のコピーを機密資料のコピーと偽って乙に渡し、残金の100万円を受け取った行為について、詐欺罪（246 I）成立

↓

不法原因給付である点は障害とならない

↓

- 4 窃盗罪と1項詐欺罪が成立し、両罪は併合罪（45前段）の関係に立つ

### 第2 乙の罪責

窃盗罪の教唆犯（61 I）が成立する



## 第 1 甲の罪責

1 甲がコピー作成目的で A 会社の機密資料（以下「本件資料」という。）を社外に持ち出した行為につき、窃盗罪（235 条）又は業務上横領罪（253 条）の成立が考えられる。

この点について、本件資料の占有が A 会社に帰属していれば前者を、甲に帰属していれば後者を検討することになる。

本問において、甲が「保管し、時折は研究のため自宅に持ち帰っていた」ことを重視すれば、甲に占有が帰属していたとも考えられなくはない。しかし、甲が職制上いかなる地位にあったのか問題文では明らかではないが、機密資料については、室長や部長等の上級管理職に事実上の支配が会社から委ねられており、単なる技術職員には、事実上の支配も帰属していないのが一般である。

したがって、占有は A 会社にあったものと解すべきである。

2 そこで、以下窃盗罪の成否を検討する。

(1) まず、本件資料は 235 条の「財物」に当たるか。

確かに、「財物」とは物理的に管理可能な物を指すところ、情報自体は物理的に管理可能な物ではなく、「財物」には当たらない。また、「財物」には財産罪によって保護されるべき一定程度の価値が要求されるところ、媒体自体も財産的価値があまりに低廉にすぎ、「財物」に当たらない。

しかし、媒体自体の経済的価値が非常に低廉であっても、情報が化体されていることによって有体物たる媒体の価値は上昇する。

1

このような意味において媒体が「財物」に当たる場合がある。

本件資料は、仮に媒体としての価値が極めて低廉であったとしても、A 会社が多額の費用を投じて研究開発した新技術に関する情報が記載されているのであるから、上記のような意味において「財物」に当たると解すべきである。

(2) また、本件資料の所有権は A 会社にあることから、本件資料は同条の「他人の」にも当たる。

(3) 次に、甲の行為は「窃取」に当たるか。

「窃取」とは、他人の意に反してその者の占有を自己又は第三者に移転することを意味する。

上記甲の行為は、A 会社の合理的な意思に反して、本件資料の占有を自己に移転するものであるから、「窃取」に当たる。

(4) また、甲には、上記(1)～(3)に対応する認識もあるから、故意に欠けるところもない（38 条 1 項）。

(5) では、甲に不法領得の意思は認められるか。

まず、領得罪の成立に当たっては、不法領得の意思の有無を判断する必要がある。かかる主観的超過傾向を不要とすれば、不可罰な使用窃盗と窃盗罪との区別、さらに、窃盗罪と毀棄罪との区別が困難になるからである。

そして、その内容としては、①権利者を排除して他人の物を自己の所有物として（権利者排除意思）、②その経済的用法に従いこれを利用・処分する意思（経済的利用処分意思）であると解する。

2

甲が行った、コピー作成目的での30分という短時間の社外持ち出し程度の行為は、一時使用目的として社会通念上一般に許容されるようにも思われる。しかし、利用可能性の侵害の程度は軽微であっても、本件資料に記載された上記のような情報の価値の消耗を伴う利用態様であって、社会通念上許容されるものではない。

したがって、①権利者排除意思は認められる。

また、甲は本件資料そのものから経済的効用を得ているわけではなく、そこに記載されている情報から経済的効用を得ているにすぎないから、②利用処分意思が認められないとも考えられる。

しかし、このような機密資料については、一般的にいて、媒体そのものの経済的価値は低く、そこに記載されている情報に経済的価値が見出されているのである。そうすると、資料そのものとそこに記載されている情報は経済的にみて一体であるといえるから、そこから経済的利益を享受しようとする意思が認められる場合には、②経済的利用処分意思には欠けるところがないと解すべきである。

したがって、甲に不法領得の意思が認められる。

(6) 以上により、甲に窃盗罪(235条)が成立する。

3 甲が、別の資料のコピーを機密資料のコピーと偽って乙に渡し、残金の100万円を受け取った行為については、「人を欺いて財物を交付させた」ものとして、詐欺罪(246条1項)が成立する可能性がある。

(1) 甲が個人的に所有する別の資料のコピーをA会社の機密資料のコ

3

ピーであると偽った行為は「欺」罔行為に当たり、これによって、乙は錯誤に陥って、残金の100万円を甲に「交付」したのであるから、処分行為及びそれに基づく占有移転も認められる。

したがって、甲には、詐欺罪が成立する。

(2) この点について、乙は後述のように甲にA会社の資料を不正に持ち出させることを教唆しており、100万円はその資料の対価であるから、かかる甲乙間の契約は不法契約に当たり、乙の給付は不法原因給付(民法708条)に当たる。

そうすると、乙には財産的損害がなく、詐欺罪は成立しないとも考えられる。

しかし、交付する財物・財産上の利益そのものは、交付するまでは不法性があるものではなく、むしろ欺罔行為によって被害者の適法な財産状態を侵害するものである。

したがって、被欺罔者が不法契約に基づいて金銭を交付したことは詐欺罪の成否に影響しない。

よって、問題なく詐欺罪が成立すると解すべきである。

4 以上により、甲には、窃盗罪と1項詐欺罪が成立し、両罪は併合罪(45条前段)の關係に立つ。

## 第2 乙の罪責

乙が上記甲の窃盗行為を、「企て」「依頼し」たのであるから、他人をそそのかして犯罪を実行する決意を生じさせたものとして、窃盗罪の教唆犯(61条1項)が成立する。

以上

4